

**Rehace expediente en: Revuelta, Miriam Susana c/ Ruben Ismael Botallo -
Disolución de sociedad de hecho
CCivCom 2ª Córdoba
Auto 538**

Y CONSIDERANDO:

Los Sres. Vocales Dres. Jorge Horacio Zinny y Marta Nélida Montoto de Spila, dijeron:

1) Que lo expuesto anteriormente tiene su debida corroboración en la norma legal citada ya que la Sra. Vocal excusante dictó pronunciamiento sobre lo principal en estos autos, como Juez de 1ª Instancia.

2) Que a tales efectos se ha llamado para intervenir en los presentes autos y en su caso en el principal al Sr. Vocal de la Excma. Cámara Tercera de Apelaciones en lo Civil y Comercial Dr. Carlos Ernesto Gavier Tagle, a quien le ha correspondido en turno y ha adoptado el llamamiento.

El Sr. Vocal Dr. Carlos Ernesto Gavier Tagle, dijo: Que la excusación de la Dra. Chiapero de Bas resulta tan cómoda como jurídicamente injustificada, lo que torna ineluctable su desestimación:

a) porque el art. 17 inc. 16 del C. de P.C. -haber dictado pronunciamiento en el pleito como juez, en una instancia inferior-, en el que se funda la petición de apartamiento, no puede reputarse aplicable en la especie, dada la absoluta inatención entre lo resuelto por la doctora Bas en primer grado (rechazo de una demanda de disolución de hecho) y lo que hoy constituye la materia de apelación (derecho a percibir honorarios por la actuación en el incidente regulatorio y eventual inconstitucionalidad del art. 107 del C.A.);

b) porque dicha norma no puede interpretarse de manera literal, sino atendiendo a la "mens legis" que anida en su texto: el sentido irrefragable del precepto mira a la necesidad de asegurar el derecho de defensa, raigalmente constitucional, mediante la preservación del principio de la doble instancia instituida por el legislador. De lo que se trata es de evitar que un magistrado se erija en juez de su propia sentencia o resolución dictada en una instancia inferior. Así lo explica Ferrer Martínez: "...se da la posibilidad de que alguien que haya estado en una instancia inferior como juez, sea designado juez de cámara, y venga a tener que

revisar por vía del recurso de apelación la decisión por él tomada en primera instancia. Podría ocurrir... que también fuera designado ministro de la Corte Suprema o Vocal del Tribunal Superior, en cuyo caso resulta indebido que pueda juzgar en la alzada de su propia decisión" ("Código...", Ferrer Martínez - Director - Advocatus, 2000, T. I, págs. 101 y 102). En consonancia, es incontrastable que para la operatividad de la norma no es bastante que el juez haya resuelto en primer grado cualquier cosa: por el contrario, es imprescindible que exista un vínculo o conexión entre el pronunciamiento dictado en esa sede y lo que constituye la materia del recurso llegado a conocimiento de la Cámara. Así, "exempli gratia", si un magistrado dicta en primer grado una resolución dirimiendo una discusión inicial de tasa de justicia, sin abrir juicio sobre el fondo de la acción deducida, mal podría excusarse en la alzada para dictar sentencia respecto de lo principal. En definitiva, si en una instancia anterior el juez no incurrió ni remotamente en prejuzgamiento respecto de la causa que llega a su decisión en la alzada, no existe motivo válido de apartamiento fundado en el art. 17 inc. 16 del C. de P.C.. Tal y no otra es la recta exégesis de la disposición en análisis, en la que prevalece su indiscutible sentido por encima de su texto ("*litera occidet, spiritu vivificat*");

c) porque sentado lo expuesto, no es dable cohonestar un pedido de apartamiento alegremente deducido: el inhibido se sustrae del cumplimiento de sus obligaciones funcionales violenta moralmente a sus colegas, que -en nombre del malhadado "espíritu de cuerpo"- se sienten obligados a admitirlo, recarga injustamente la tarea del juez de otro tribunal convocado en su reemplazo, dilata considerablemente la resolución de los litigios, y redundante de tal manera en detrimento de los justiciables;

d) porque además, la admisión de una inhibición carente de todo sustento también tiene otras connotaciones que conspiran contra el buen orden de los procesos: si bien cualquiera de las partes sólo puede recurrir la resolución respectiva vía reposición, una vez dictada la decisión definitiva de la causa queda expedita la casación por vicio de pronunciamiento (art. 383 inc. 1º, C. de P.C.), mediante la cual es dable hacer valer con muy buen suceso la desviación consistente en la violación del principio del juez natural; ni hablar del imaginable dispendio de tiempo y gastos, y la consiguiente imagen tan poco plausible de la Administración de Justicia;

e) porque, en suma, en el caso de autos ni siquiera puede hablarse de una actitud que exuda un criterio hermenéutico extremadamente amplio en la interpretación de una norma, sino más bien de su lisa y llana violación.

En consonancia, y sin mengua del profundo respeto y afecto que les profeso a mis distinguidos colegas de la Cámara Segunda, a la vocal inhibida "ad limitum" como a sus pares adjutores, voto por el rechazo de la excusación inane, impetrada de balde.

Por todo ello,

SE RESUELVE:

I) Hacer lugar a la excusación de la Dra. Silvana María Chiapero de Bas y, en consecuencia, tenerla por apartada del conocimiento de la presente causa.

II) Tener por integrado el Tribunal con los Sres. Vocales Dres. Marta Nélida Montoto de Spila, Jorge Horacio Zinny y Carlos Ernesto Gavier Tagle.

III) Protocolícese y hágase saber la presente resolución.

Fdo.: Zinny - Montoto de Spila - Gavier Tagle.